

1500278-91.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AVELINO SOARES VIEIRA NETO

Data da Audiência:

05/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500278-91.2022.8.26.0571 - Controle 2022/000329

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AVELINO SOARES VIEIRA NETO

Data da Audiência:

05/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o Acusado Avelino Soares Vieira Neto, que se encontra em liberdade e foi devidamente intimado às fls. 157. Ausente também, a testemunha Nilton Alves de Proença, intimado às fls. 162. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Marcelo Garcia da Costa e Fabrício Mascarello Machado Rodrigues arroladas pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Nilton Alves de Proença, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Decreto a revelia do acusado e não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm

comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão do réu narraram, em tom unânime, que receberam notícia do tráfico praticado por um indivíduo no local, apontando as vestimentas e o ponto em que acondicionava as drogas, próximo a um pé de mamona. Então dirigiram-se até o local e puderam avistar o momento em que o acusado, a quem identificaram pelas roupas, que coincidiam com a denúncia, entregando algo para terceira pessoa, pelo que os abordaram, sendo que o indivíduo que havia adquirido as drogas foram localizados dois pinos de cocaína, tendo ele admitido que havia acabado de comprar do réu. No terreno baldio, justamente como informado, localizaram e apreenderam outros setenta e quatro pinos da droga, embalados de forma similar aquelas encontradas com o usuário Nilton, e que estavam ali acondicionadas pelo acusado para ulterior entrega ao consumo de terceiros. Ademais, o valor de R\$ 20,00 também foi encontrado em posse do acusado, valor esse que havia recebido pela venda do entorpecente. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição dos milicianos; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Dessa forma, é patente a responsabilidade penal do acusado pelo delito tipificado no artigo 33 da lei de prevenção e repressão às drogas, haja vista as circunstâncias em que se deu a prisão, evidenciando a venda e também que os entorpecentes que tinha em sua pochete era destinada à ulterior entrega ao consumo de terceiros.. No mesmo diapasão, a prova deita por terra a versão aduzida pelo réu em seu interrogatório judicial, negando a posse dos entorpecentes, a qual não merece guarida, haja vista que isolada nos autos, e contrariada pelas palavras seguras e de convicção apresentada pelos policiais, no sentido de que a ele pertenciam os entorpecentes encontrados e eram destinados ao comércio. Aliás, não há como se aceitar em seu favor que a alegada condição de usuário venha a elidir o tráfico, até porque bastante comum nos dias atuais o comércio ilícito de drogas até para sustento do vício. Demonstradas, pois, autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, devendo, ademais, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção privativa de liberdade. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: A Defensoria Pública representa o acusado, que foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado, pelas razões a seguir. I. DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. Da absolvição por insuficiência de provas. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. O policial Marcelo Garcia da Costa, ouvido em juízo, declarou que avistaram um indivíduo entregando algo para outro indivíduo que estaria dentro de um carro. O sujeito que estava no carro foi abordado e possuía 2 pinos de cocaína. O réu, que estava na rua, nada possuía, apenas dinheiro. O sujeito que estava no veículo é que disse que o réu lhe vendeu entorpecentes, tendo indicado de onde a droga foi retirada. No terreno baldio, encontraram mais cocaína. A testemunha policial Fabricio Mascarello Machado Rodrigues deu depoimento semelhante ao colega de farda. Ocorre que NILTON, o suposto usuário, sequer compareceu em juízo para ratificar a versão apresentada em solo policial. É certo, ainda, que Nilton era a pessoa que estava na posse de entorpecente e, portanto, tinha motivos para justificar o ilícito que cometia e para incriminar o réu. Ademais, o réu não foi visto mantendo contato com qualquer pessoa (exceto o próprio Nilton), nada de ilícito foi apreendido em seu poder e não havia qualquer denúncia formalizada contra si. É de se destacar, ainda, que apesar de não ter comparecido em juízo, negou veementemente as imputações em solo policial (fls. 10-11). A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO

NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitiva. Finalmente, quanto ao regime inicial, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pugna-se, por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. AVELINO SOARES VIEIRA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 13 h, na Rua Taquarituba, n. 350, Vila Paulo Ayres, nesta Cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, setenta e quatro microtubos contendo “cocaína”, com peso de 10,31 gramas, bem como vendeu dois microtubos contendo “cocaína”, com peso de 0,20 gramas. Notificado por edital, fls. 132, e após, pessoalmente, fls. 134, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 138/139. A denúncia foi recebida, fls. 140/141 e o Réu, citado, fls. 157. Durante a audiência

de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes. Foi decretada a revelia do Réu. Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 16/18, no Laudo de Constatação, fls. 24/25, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 28/29, bem como nos Exames químico-toxicológico n. 64.376/2022 e n. 66.620/2022, fls. 102/105 e fls. 106/108, constatando-se a presença dos princípios ativos COCAÍNA. Marcelo Garcia da Costa e Fabrício Mascarello Machado Rodrigues, policiais militares, testemunhas, disseram que estavam em patrulhamento e foram acionados para atendimento de denúncia de tráfico de entorpecentes, então foram ao local, quando viram Nilton no interior do veículo, o qual recebia algo do Réu; feita a abordagem, com o motorista do carro os policiais encontraram duas porções de “cocaína”, tendo Nilton afirmado que tinha acabado de comprar as porções do

Acusado por R\$ 20,00, quantia encontrada com o Réu; foram ao ponto onde o Acusado escondia as porções e encontraram, embaixo de uma tábua de madeira, próximo à árvore, um saco plástico contendo dezoito pinos de “cocaína”. Segundo a Testemunha Marcelo, o próprio usuário indicou o local de onde o Réu retirava as drogas, que era o mesmo da denúncia. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em serviço quando receberam informações de tráfico de entorpecentes e, ao chegarem ao local, viram o Réu entregar algo a um usuário, e, de fato, no carro do adquirente havia duas porções de “cocaína”, e, com o Réu, os policiais encontraram a quantia de R\$ 20,00, exatamente a mesma que o comprador disse aos policiais que havia entregado ao vendedor pelas duas porções de “cocaína” encontradas no seu veículo. Com toda certeza o Réu, para poder vender, utilizava algum local para esconder as porções, e os policiais encontraram, embaixo de uma tábua, próximo a uma árvore, um saquinho com dezoito porções, drogas que, pela quantidade, forma de partilha e todas as circunstâncias já descritas, destinavam-se ao comércio ilícito. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: “É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu guardava, mantinha em depósito e vendeu substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no “caput”, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, “in casu”, foi a de guardar, manter em depósito e vender, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, “caput”, do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: Não há. Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena

decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar AVELINO SOARES VIEIRA NETO, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 05 de outubro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA